

1501629-49.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIZ MARCONDES PONTES

Comarca: Capivari

Foro: Foro de Capivari

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANE PEREIRA DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ MARCONDES PONTES

Vistos.

GIOVANE PEREIRA DOS SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) art. 33, caput, da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capivari

Foro de Capivari

2ª Vara

Rua Dr. João Adolfo Stein, 171, Capivari - SP - cep 13360-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1501629-49.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501629-49.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANE PEREIRA DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ MARCONDES PONTES

Vistos.

GIOVANE PEREIRA DOS SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), porque, segundo narrou a denúncia, o réu, no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 17h 00min., na Rua Dois, nº 237, Bairro Santa Tereza Davila, no centro de Capivari, possuía, trazia consigo, para o fim de tráfico, assim como efetivamente vendia, 24,7 gramas de maconha, substância essa capaz de gerar dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal..

A denúncia foi oferecida em 12/11/2021 (fls. 83/84) e recebida em 17/11/2021 (fls. 80/91).

Citado em 16/01/2022 (fls. 106), o réu apresentou sua resposta à acusação à fls. 110/113.

Realizada a audiência de instrução e julgamento nesta data, foram ouvidas a três testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em seguida, as partes se manifestaram, oralmente, em alegações finais.

É o relatório. Passo a fundamentar.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não havendo quaisquer preliminares alegadas pela Defesa ou pelo Ministério Público, passo, pois, a conhecer diretamente do mérito.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, boletim de ocorrência de fls. 08/10, auto de exibição e apreensão de fls. 11/13, laudo de constatação de fls. 15/17 e laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 153/155.

Como se nota, inequívoca a apreensão de uma única porção de maconha, apresentando massa líquida de 24,7 gramas.

A autoria também restou devidamente comprovada nos autos.

Ouvido em juízo como testemunha, o GCM Cristiano narrou, em breve síntese, que estava em patrulhamento pelo Bairro Santa Tereza D'Ávila, quando ingressou na rua em que o réu se encontrava; que o réu se encontrava na companhia de um indivíduo sobre uma motocicleta; que avistou o réu entregando algo ao motociclista; que, diante da fundada suspeita, ambos foram abordados; que o motociclista confirmou que estava no local para comprar drogas de Giovani e que Giovani confessou a traficância; que na posse de Giovani foi encontrada uma única porção de maconha.

Ouvido em juízo como testemunha, o GCM Esli narrou idêntica versão. Acrescentou que viu Giovani fazer gesto de entrega ao motociclista; porém não conseguiu ver se era dinheiro ou droga.

Ouvido em juízo como testemunha, Thiago narrou, em breve síntese, que foi comprar uma porção de maconha do réu; que já tinha comprado maconha do réu uma única vez; que deu R\$ 100,00 ao réu Giovani; que, no momento em que Giovani iria entregar as drogas ao depoente, foi abordado pelos guardas civis; que, antes de comprar as drogas, mandou mensagem para Giovani dizendo que iria pegar a droga naquele local. Interrogado, o réu negou a prática do crime. Disse que, no dia dos fatos, não estava vendendo drogas; que Thiago telefonou para ele para que comprassem drogas juntos para consumo compartilhado; que quando iriam comprar as drogas juntos, foi abordado pelos guardas civis.

Em que pese a negativa do denunciado, entendo que ficou bem comprovada a prática do crime.

De fato, os guardas civis confirmaram que flagraram o réu e a testemunha Thiago em uma transação: Thiago estava sobre uma motocicleta e Giovane estava entregando algo a ele. A entrega não pode ser consumada, diante da abordagem dos guardas. Em revista pessoal, Giovani de fato trazia uma porção de drogas em suas mãos, justamente aquela que iria ser entregue a Thiago.

Deste modo, embora tenha sido apreendida uma única porção de maconha, o réu foi flagrado vendendo a droga. Thiago esclareceu como tudo se deu: ele entregou o dinheiro a Giovani e este foi buscar a droga; quando retornou com a porção, foi abordado pelos guardas civis.

Portanto, ficou bem comprovado que Giovani praticou o tráfico de drogas, na forma do art. 33 da Lei de Drogas, porque trazia consigo uma porção de maconha destinada à venda, venda esta que estava na iminência de ser concretizada e apenas não se consumou ante a efetiva ação dos guardas civis.

É válido esclarecer que entendo não haver qualquer vício na atuação dos Guardas Civis Municipais. Isso porque, o crime de tráfico de drogas é considerado um crime permanente, cujo estado de flagrância se perpetua no tempo. Assim, não há qualquer ilegalidade na atuação dos guardas que, visualizando uma situação de flagrante delito, agem para cessar a sua prática. Aliás, trata-se de conduta que homenageia a função pública que exercem, na medida em que, a despeito de não estar inserida no

âmbito da função precípua que exercem (proteção dos bens, serviços e instalações do município), os guardas não se omitiram diante da prática do crime que estava sendo cometido às suas vistas. Ademais, à luz do art. 301 do Código de Processo Penal, na medida em que os agentes da Guarda Municipal também podem ser incluídos no conceito de "autoridades policiais e seus agentes", estes possuem o dever legal de agir quando diante de um flagrante delito.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"Embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, §8º da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator (...) (STJ, HC 109.592-SP, 5ª Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 18.2.2010, Dje 29.3.2010).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. MEIOS ILÍCITOS. OBTENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. INTELIGÊNCIA. 1. Qualquer um do povo pode prender quem se encontre em flagrante delito, não obstante a atribuição da Guarda Municipal atribuída pela Constituição (ex vi, art. 144, § 8º, da CRFB/1988), o que revela a legalidade da hipótese dos autos. Inteligência do art. 301 do CPP. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, 6ª Turma, AgInt no AREsp 950569, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 21/02/2017).

Por oportuno, consigno que não há nada nos autos a afastar a credibilidade ou veracidade das versões trazidas pelos guardas civis.

Cumprе salientar que o depoimento dos guardas civis, como de policiais em geral, é válido como outro qualquer, pois o artigo 202 do Código de Processo Penal dispõe que qualquer pessoa pode ser testemunha, não trazendo qualquer distinção entre policial e não policial. Além disso, o pensamento no sentido de que os testemunhos prestados por policiais devem ser recebidos com cautela, apenas e tão somente pelo simples fato de que tais agentes pretenderiam justificar a legalidade e legitimidade de suas ações, vem a muito sendo rebatida, devendo, assim, ser levados em conta com a credibilidade que as circunstâncias do caso concreto permitem lhe atribuir. Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. PENAL. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA: EXAME. I. - O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento. II. - Não é admissível, no processo de habeas corpus, o exame aprofundado da prova. III. - H.C. indeferido". (STF - Rel. Min. Marco Aurélio - J. em 04/08/1998 - 2ª. Turma - HC 76557 / RJ - Rio de Janeiro).

Entendo que o testemunho de policiais não merece maior ou menor valor pelo simples fato de integrarem o sistema de segurança pública estatal. Entender que todo testemunho prestado policial é verdadeiro é tão equivocado quanto entender que todo testemunho prestado policial é falso. Os depoimentos devem ser valorados a partir de sua consistência, coerência e das circunstâncias fáticas vivenciadas pelo depoente.

E, nessa linha de raciocínio, não há qualquer explicação plausível para as testemunhas acusarem injustamente o réu, pois não possuem qualquer desavença anterior contra ele. O pensamento razoável leva a crer que um indivíduo, em sã consciência, jamais acusaria outro da prática de delito sem possuir motivações para acusá-lo. Sendo assim, todo o argumento que vise a impugnar suas palavras deve ser recebido com extrema cautela e, na maior parte das vezes, será mero subterfúgio da defesa pela absolvição por falta de provas.

Conclui-se, portanto, que, no presente caso, a prova testemunhal produzida, em conjunto com os demais elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação do réu. Como dito, a palavra dos policiais, tendo em vista a ausência de motivo para que ela seja desacreditada, tendo sido apresentada de forma consistente, coerente, crível e em conjunto com os demais elementos de prova existente nos autos, merece ser respaldada no presente caso.

Dosimetria da pena

Conforme certidão de fls. 98/99, o réu é primário e não ostenta antecedentes. A pena prevista para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atentando para o quanto disposto no art. 59 do Código Penal, à luz do critério de preponderância estabelecido pelo artigo 42 da Lei 11.343/2006, entendo que a reprovabilidade é comum à espécie, motivo pelo qual fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, embora presentes circunstâncias atenuantes, quais sejam, agente menor de 21 anos na data dos fatos, não é admissível reduzir-se a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.").

Não existem causas de aumento, porém incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois, não havendo prova contundente nos autos de que o réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, pode-se presumir que não se dedique, de forma permanente e habitual, à atividade criminosa de traficar drogas, reiteradamente, ou que seja integrante de organização criminosa, situação especial que exige prova cabal e não mera conjectura. Não havendo prova de que o réu integre organização criminosa ou se dedique de forma habitual a atividades criminosas, afastar-se a aplicação do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06 incorreria em grave violação ao ônus probatório do processo penal, prejudicando o réu de forma sobremaneira em razão de uma mera presunção, e não por um fato comprovado nos autos.

De fato, a quantidade de droga apreendida, por si só, não revela que o réu se trata de grande traficante, ou, ainda que pequeno traficante fosse, integra organização criminosa ou se dedica às atividades criminosas. Além disso, é primário, não possuindo antecedentes. Finalmente, não há sequer indício de que o réu integre organização criminosa ou que seja traficante profissional.

A alegação de que, pelo simples fato de trazer consigo drogas é indicativo de que ele integra organização criminosa ou se dedica às atividades criminosas representa presunção inadmissível no processo penal. Aliás, é conclusão que sequer se sustenta do ponto de vista lógico, já que é logicamente possível (e porque não, corriqueiro), que o indivíduo pratique o tráfico de drogas de forma pontual em sua jornada. Se não há prova de que ele se dedica às atividades criminosas ou integre organização criminosa é direito subjetivo do condenado a redução de pena prevista no § 4º, art. 33, da Lei de Drogas.

Observo que, para fim de progressão e de concessão de outros benefícios, deverá ser observado que o crime praticado não é hediondo ou equiparado (STF, HC nº 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, J. 23/06/2016), de modo que a progressão poderá ser concedida com o cumprimento de um sexto da pena, o livramento condicional pode ser concedido com o desconto de um terço da pena, e pode haver a concessão de indulto e de comutação de penas ao acusado.

Dessa feita, diante de tal causa de diminuição de pena, legalmente estipulada em 1/6 a 2/3, entendo que, no caso, considerando que a quantidade de drogas não é expressiva, entendo pela aplicação do patamar máximo de redução, motivo pelo qual fixo a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Ausentes outras causas de diminuição ou de aumento de pena, torno-a definitiva.

Em respeito ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 1.052.700 (Tema 972), em que se fixou a seguinte tese "é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal", considerando, portanto, os parâmetros fixados no art. 33, § 2º, do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Deixo de aplicar o art. 387, parágrafo segundo, CPP, isto é, computando o tempo de prisão provisória para a definição do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que não há nos autos elementos que permitam a aferição da conduta carcerária do réu, de forma que ao juízo da execução é que cabe, assim que receber a guia de

execução, provisória ou definitiva, avaliar a possibilidade de detração e progressão do réu a regime menos afilitivo.

Atento que o tráfico privilegiado não é hediondo ou equiparado (STF, HC nº 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, J. 23/06/2016), presentes os requisitos que autorizam a substituição da pena, nos termos do art. 44, § 2º do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; e b) prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a ser paga na forma estipulada pelo juízo da execução. A prestação de serviços à comunidade deverá ser cumprida junto a entidades assistenciais ou outros estabelecimentos congêneres (artigo 46, caput), à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.

Decido.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR GIOVANE PEREIRA DOS SANTOS como incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado segundo o INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática para Atualização de Débitos Judiciais do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo até o efetivo pagamento. Nos termos da fundamentação acima, a pena privativa de liberdade é substituída por: a) prestação de serviços à comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; e b) prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a ser paga na forma estipulada pelo juízo da execução.

Diante quantidade de pena imposta, atento ao regime aberto para o início do cumprimento da pena, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Caso ainda não tenha sido realizada tal providência, nos termos do art. 50, §3º, da Lei 11.343/06, autorizo a destruição das drogas apreendidas, com a ressalva das amostras guardas para contraprova. Cópia digitalmente assinada da presente sentença valerá como ofício à autoridade policial.

Com o trânsito em julgado, nos termos do art. 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, fica desde já autorizada a destruição das amostras guardas para contraprova, oficiando-se para tanto.

Nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, determino o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União (FUNAD). Com o trânsito em julgado, remeta-se à SENAD relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, o local em que se encontram e a entidade ou o órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente.

Condenação à taxa judiciária. Condene o(s) réu(s), na forma do art. 804 do Código de Processo Penal e da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º, ao pagamento da taxa judiciária, observado, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio, o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil ("Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.")

Expedição de certidão do Convênio OAB/DPE. Em caso de defesa patrocinada por meio do Convênio OAB/DPE, aguarde-se o decurso do prazo para interposição de recurso. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários (para pagamento de 100% do valor previsto na tabela). Na hipótese de interposição de recurso por qualquer uma das partes, expeça-se certidão de honorários, observando-se a seguinte regra do Convênio: "nos processos criminais de competência do Juízo singular, após a sentença condenatória ou absolutória com interposição de recurso por quaisquer das partes, 70% (setenta por cento) do valor previsto na tabela por ocasião da sentença e, os 30% (trinta por cento) restantes, após o trânsito em julgado do acórdão."

Expedição de guia de execução provisória. Interposto o recurso, em caso de réu(s) preso(s), expeça-se guia de execução provisória. Após o trânsito em julgado, (a) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); (b) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (c) expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se. Capivari, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA